

1500842-88.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial

Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500842-88.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500842-88.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2090050/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 17120126 - DEL.POL.CAJAMAR, 565/21/401 - DEL.POL.CAJAMAR, 565/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 2090050 - 01º D.P. CAJAMAR, 565/21/401 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ROSA DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, tombado sob o nº 310/16, ofereceu denúncia em face de GABRIEL ROSA DE LIMA, devidamente qualificado nos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos: Consta da denúncia que, no dia 01 de abril de 2021, às 17h15, na Rua Cruzeiro, 18, Bela Vista, nesta Cidade e Comarca de Cajamar, GABRIEL ROSA DE LIMA, trazia consigo e guardava, nas imediações da Igreja Assembléia de Deus Ministério Belém, para fins

de tráfico de drogas, 4 eppendorfs de cocaína; 2 porções de maconha; 45 eppendorfs de cocaína, 21 invólucros de maconha; 47 pedras de crack e um comprimido de Ecstasy, substâncias capazes de causarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, proveniente do tráfico.

Convertida, em sede de plantão judiciário, a prisão em flagrante do denunciado em prisão preventiva em 02/04/2021 (f. 72-73).

Laudo de exame químico de entorpecente acostado (f. 179-183).

A denúncia foi recebida em 10/05/2021 (f. 135-136), o réu foi regularmente citado (f. 152) e ofereceu defesa prévia (f. 157-158).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (f. 166-167), prosseguiu-se à fase instrutória, momento em que foram ouvidas testemunhas, sendo o réu, ao final, interrogado.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

A Defesa, por seu turno, pugnou por benefícios no tocante à pena.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de GABRIEL ROSA DE LIMA pela prática do fato delituoso disposto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

De fato, assiste razão ao Ministério Público.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (f. 1), boletim de ocorrência (f. 9-12), auto de exibição e apreensão (f. 13-14), auto de constatação da natureza tóxica (f. 18-26) e laudo pericial químico de entorpecente (f. 179-183), que atestou que as substâncias encontradas se tratava de THC, anfetamina e cocaína, que são de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado GABRIEL ROSA DE LIMA.

Inquirida, a testemunha PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, guarda municipal, disse que, em patrulhamento por via conhecida pelo tráfico, percebeu que o acusado passou a andar olhando para trás, demonstrando certo nervosismo. Feita a abordagem, encontraram os entorpecentes citados na denúncia, além de notas de dinheiro. Aduziu que o réu confessou a prática do delito e que mostrou onde estava o restante da droga, localizada em terreno baldio, embaixo de uma pedra.

A testemunha JEIMES ULISS CAMPOS FELISBINO, guarda municipal, disse se recordar do réu. Teceu relato semelhante ao manifestado por seu companheiro de farda. Afirmou que o dinheiro encontrado estava em notas fracionadas.

Interrogado, o acusado GABRIEL ROSA DE LIMA disse que, de fato, praticou os fatos a ele imputados, e que ganharia 150 reais para realizar a intermediação entre as drogas e os usuários.

Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra do acusado se encontra em consonância do conjunto probatório, em especial das testemunhas guardas municipais que efetuarão a diligência de apreensão das substâncias.

Inicialmente, não há por que se desconfiar da palavra dos guardas municipais, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça.

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato de o agente manter em depósito e trazer consigo drogas para entrega e consumo de terceiros, o que ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou

de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Ademais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irreabilidade.

Nada indica que os policiais tenham criado uma situação para acusar falsamente o acusado. A presunção iuris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.

Registre-se, ademais, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Ainda que assim não fosse, o réu confessou o delito. Sobre a grande importância da confissão judicial, Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122).

Trilhando caminho semelhante há o entendimento da jurisprudência:

"Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

Por fim, com relação à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, friso que está devidamente caracterizada, porquanto, como se denota do croqui de f. 134 e da prova oral coligida, a Igreja Assembléia de Deus está localizada 94 metros do local dos fatos, de modo que comprovado o cometimento do delito na imediação de uma Igreja, local de grande movimentação de pessoas. Insta consignar que os locais indicados no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, em virtude da maior concentração de pessoas, sobretudo jovens, crianças e pais, e, por esta razão, representam maior risco à saúde pública. Nesse ponto, ressaltar que é dispensável a comprovação de que o acusado visava à comercialização de drogas em relação aos seus frequentadores para que haja a incidência da majorante em tela. Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da causa especial de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que restou devidamente comprovado que o paciente atuava próximo a um estabelecimento de ensino, pouco importando se ele estava ou não visando especialmente atingir estudantes desse estabelecimento ou efetivamente comercializando entorpecentes diretamente com os alunos da escola. 2. Ordem denegada". (HC 181.050/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 19/03/2012).

Com efeito, os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo estão tranquilamente comprovados nos autos: a quantidade de entorpecente (45 eppendorfs de cocaína, 21 invólucros de maconha; 47 pedras de crack e um comprimido de Ecstasy); o modo de acondicionamento (invólucros plásticos, embalados individualmente e prontos para o comércio); a questionável a origem financeira dos valores apreendidos (R\$ 100,00, em notas trocadas), eis que nenhuma prova idônea foi trazida aos autos para comprovar sua licitude; o local onde se deram os fatos (conhecido ponto de tráfico de drogas); revelam que se tratava sim da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque, apesar de tecnicamente primário, o comércio de substância altamente letal ao ser humano (crack) impõe uma elevação nas penas bases, no montante de 1/6, resultando-se em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, encontram-se presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa, vez que o acusado, à época dos fatos, contava com 20 anos (f. 5), e da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP), motivos pelos quais retorno as penas anteriormente fixadas ao patamar mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase de cálculo penal, considero presente a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porquanto, como já exarado, restou comprovado o cometimento do delito nas proximidades de uma igreja. Assim, aumento em 1/6 a pena, obtendo-se como resultado o total de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Por outro lado, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o acusado é primário, portador de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

No entanto, para evitar bis in idem deixo de valorar a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos. Nesse aspecto:

"Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência. Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio." (Brasília residência, 1º de abril de 2014. Ministro MARCO AURÉLIO).

Desta feita, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3, totalizando 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 183 dias-multa, penas que torno definitivas, vez que inexistem outros elementos modificadores.

À míngua de elementos acerca da capacidade financeira do acusado, fixo o valor do dia-multa no piso legal.

Em atenção ao artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nesse ponto, ressalto recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico de drogas, na forma privilegiada não possui natureza hedionda:

“Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida.” (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, verifico que o regime inicial aberto se mostra mais adequado, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, da primariedade e conduta social e personalidade favoráveis, não obstante a alta lesividade da substância entorpecente apreendida.

E, pelos mesmos motivos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação, a ser indicada pelo juízo da execução; e multa de 2 salários-mínimos vigentes, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR GABRIEL ROSA DE LIMA, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput c.c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no piso legal; substituída a primeira por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação, a ser indicada pelo juízo da execução; e multa de 2 salários-mínimos vigentes, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Não estando configurados os requisitos ensejadores da custódia cautelar do acusado e tendo em vista o quantum de pena aplicada, bem como a sua substituição, de todo incompatíveis com a prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se o alvará de soltura clausulado, se por outro não estiver preso.

Condene o réu nas custas processuais, ressalvada a hipótese de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC.

Com o cumprimento do mandado de prisão, expeça-se a guia de recolhimento provisória, bem como carta de guia.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento definitiva;

Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários e bens apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06;

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que, após o trânsito em julgado, também deverá ser incinerada;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais,

forneendo as informações sobre a condenação do réu.
Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa e/ou das custas processuais, certifique a serventia o ocorrido, expeça-se certidão para fins da inscrição em dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);
Arbitre os honorários do(a) defensor(a) do(a) acusado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminhá-la para a Defensoria.
A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.
Publique-se.

Cajamar, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA